

1501937-69.2022.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2140114/2022 - DEL.POL.ITAPUI, 25139172 - DEL.POL.ITAPUI, 2140114 - DEL.POL.ITAPUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE ORLANDO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Virginia Mendes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501937-69.2022.8.26.0302

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2140114/2022 - DEL.POL.ITAPUI, 25139172 - DEL.POL.ITAPUI, 2140114 - DEL.POL.ITAPUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE ORLANDO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

VISTOS.

JOSÉ ORLANDO DA SILVA, vulgo "Japão", qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Notificado (fls. 162), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 166/168).

A denúncia foi recebida em 10 de agosto de 2022 (fls. 169) e o acusado foi citado (fls. 194).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogado o réu (fls. 197/198).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público postulou a condenação do acusado nos termos da denúncia (fls. 215/219).

A defesa sustentou irregularidade na atuação policial e requereu o desentranhamento da prova desta advinda, com a consequente absolvição do réu. No mérito, pugnou pela desclassificação da conduta do acusado para a prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 e, subsidiariamente, postulou a fixação da reprimenda no mínimo legal e aplicação de benesses legais (fls. 229/235).

É o relatório.
DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/11), boletim de ocorrência (fls. 12/14), auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 120/123), laudo pericial (fls. 124) e pela prova oral.

A autoria também é certa.

Interrogado em juízo, o réu negou os fatos. Disse que atendeu à ordem de parada e autorizou a busca no veículo, no qual foi encontrado o pote contendo fermento e cocaína. Disse que pegou o pote de fermento em sua casa e colocou 14g de cocaína por cima. Adquiriu o entorpecente no dia anterior aos fatos e o guardou em uma construção na qual trabalhava. A droga se destinava ao seu próprio uso e a misturava com fermento quando estava muito forte. Foi encontrado, ainda, um pino de cocaína em posse de Matheus.

Os policiais militares Flávio e Mickaell relataram, em síntese, que a abordagem do veículo do acusado decorreu de uma infração de trânsito por ele cometida e foi possível ver que no interior do carro, próximo ao câmbio, tinha um pino de cocaína. Procederam às revistas pessoais e veicular. No interior da cueca do acusado foi localizado em pote de fermento com substância branca e José Orlando alegou que se tratava de fermento utilizado por sua filha na confecção de bolos. Todavia, na delegacia houve constatação de que era cocaína. Havia denúncias de fontes confiáveis, não formalizadas, sobre a perpetração de tráfico de entorpecentes pelo acusado.

Pois bem.

Inicialmente, não se vislumbra ilegalidade na ação policial, como sustentado pela defesa. Os policiais militares relataram que abordaram o réu em razão de uma infração de trânsito e visualizaram um eppendorf de cocaína dentro do carro. Tal circunstância, associada ao fato de o réu ser conhecido por tráfico nos meios policiais da pequena cidade de Itapuí, revelava fundada suspeita da situação de flagrância de ato ilícito e respaldava as buscas realizadas. De qualquer forma, o réu afirmou em juízo que autorizou a busca em seu automóvel pelos policiais.

No mérito, as provas são suficientes para segura comprovação do crime narrado na denúncia.

A pueril versão do acusado acerca da mistura accidental da cocaína com fermento, a fim de justificar sua alegação de que a significativa quantidade de droga apreendida seria exclusivamente para seu uso, não encontra qualquer respaldo nos autos. Não é crível que um usuário intencionasse esconder cocaína não embalada em cima de fermento, considerando a grande semelhança entre as substâncias.

Ademais, a destinação de entrega a terceiro restou demonstrada pela quantidade de entorpecente apreendido com o réu, em adição às informações recebidas pela polícia militar sobre a prática de tráfico pelo acusado e, ainda, nas mensagens trocadas entre o acusado e “luca tato” (fls. 421 do laudo pericial – link fl. 124) no dia dos fatos, na qual comentam sobre débito do réu com o interlocutor e, ao final, “luca” pede que o acusado: “... Traz um pouco para mim hora que vc descer ... Só um pouco ...”.

De outro lado, as narrativas dos policiais se mostraram coerentes e harmônicas com as demais provas e não foi alegado qualquer motivo concreto pelo qual eles desejassem falsamente incriminar o acusado.

Nesse contexto, não há como acolher as teses defensivas para absolvição ou desclassificação da conduta do acusado, vez que suficientemente comprovada a prática do crime narrado da denúncia.

Procedente a ação penal, passo a dosar as penas.

Atentando-se ao disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, não vislumbro motivos para majoração da pena-base, que fixo no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Presente a agravante da reincidência, conforme se vislumbra de fls. 146/148 (Processo nº 0004005-13.2015.8.26.0302). E sendo ela específica, aumento a reprimenda de $\frac{1}{4}$ para 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa.

Na terceira fase, inaplicável o disposto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, ante a reincidência do acusado.

A reprimenda deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado, tendo em vista a pena aplicada e reincidência.

A pena pecuniária deve ser fixada no mínimo legal, à mingua de elementos que denotem condição financeira privilegiada.

Por fim, a despeito das alterações promovidas pela Lei 12.736/12 no art. 387, do Código de Processo Penal, especialmente a inclusão da regra trazida no § 2º deste último dispositivo (o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade), deixo de aplicar de forma antecipada a detração penal por entender que esta lei modificadora é materialmente inconstitucional, afrontando os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da isonomia (art. 5º, da Constituição Federal). A propósito, cabe trazer a lume os ensinamentos do Prof. César Dário Mariano da Silva em recente artigo publicado na revista eletrônica Consultor Jurídico:

“O princípio da individualização da pena está previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e dispõe que caberá à lei regular a individualização da pena.

A individualização da pena desenvolve-se em três etapas: a legislativa, a judicial e a executória.

(...)

A nova lei fundiu em uma etapa a judiciária e a de execução das penas, uma vez que, ao proferir sentença, poderá o Juiz promover de regime o condenado sem atentar para a análise do seu mérito, de acordo com o previsto no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que dispõe: “A pena privativa de liberdade será executada em forma

progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão”

Com efeito, a Lei das Execuções Penais, que é especial, contém normas que devem ser observadas para a correta individualização da pena. O condenado deverá cumprir a pena privativa de liberdade em etapas cada vez menos rigorosas até obter a liberdade, devendo, para tanto, ser observado seu mérito. Sem essa análise do merecimento para a progressão de regime, inclusive com a realização do exame criminológico quando necessário, está sendo violado o disposto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, que dispõe sobre a individualização da pena.

A Lei a ser observada por ocasião da progressão de regime é a das Execuções Penais, que é especial e traz os requisitos necessários, que devem ser analisados pelo Juiz Natural da causa, que é o das Execuções Penais e não o prolator da sentença.

Destarte, somente com o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 112 da Lei das Execuções Penais é que poderá ser deferida a progressão de regime pelo Juiz das Execuções Criminais, observado o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), a teor do disposto no artigo 66, inciso III, alínea “b”, da Lei das Execuções Penais.

E se não bastassem esses argumentos, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais, com evidente violação ao princípio da isonomia.

Assim, v.g, aquela pessoa condenada à pena privativa de liberdade e que tenha sido presa provisoriamente terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovida de regime sem a observância do mérito; ao passo que o condenado, que não tenha cumprido prisão provisória, deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, “caput”, da CF)”(<http://www.conjur.com.br/2012-dez-10/cesar-dario-lei-tornar-automatica-progressao-regime> - acesso em 17.12.2012, às 00h40min)

Ressalte-se: a modificação proposta pelo legislador é capaz de gerar odiosa injustiça, na medida em que os condenados que tenham sido submetidos a custódia cautelar durante o processo (justamente porque a sua liberdade colocava em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal – art. 312, do Código de Processo Penal) seriam beneficiados em detrimento daqueles que puderam responder ao processo em liberdade, provavelmente indivíduos menos perigosos para a sociedade.

E não é só. A antecipação da detração penal acarreta a supressão, no caso de réus presos cautelarmente, das regras para progressão de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, o que também se reflete em insustentável atentado ao princípio da isonomia.

Tudo isso sem considerar a possibilidade de que o réu esteja preso em razão de prisão preventiva decretada em vários processos, quando a aplicação irrestrita do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal poderá acarretar a consideração do mesmo período de prisão cautelar para fins de detração em várias sentenças condenatórias, o que não se pode admitir.

Assim sendo, por entender que o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal viola a

disciplina constitucional, deixo de aplicá-lo, o que faço com arrimo no controle de constitucionalidade difuso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, o acusado JOSÉ ORLANDO DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 625 dias-multa, no mínimo legal.

O réu não poderá apelar em liberdade, pois permaneceu preso no curso do processo e remanescem os requisitos que ensejaram a sua custódia cautelar, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública. Recomende-se, pois, na prisão em que se encontra.

Nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento do veículo FIAT/Palio (fls. 18/19 e 28) e do telefone, usados no cometimento do delito, em favor da União.

Custas ex lege.

Oportunamente, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos.

P.I.C.

Jaú, 27 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA